

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1/2022

A LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

D. RAMON MARIA QUEROL ARAGON, Procurador de los Tribunales de Madrid, Colegiado nº 1475, en nombre y representación de **D. RICARDO ALVIRA BAEZA**, como se encuentra acreditado en los presentes autos, bajo la asistencia letrada de **D. LEOCADIO PAJARES MADRID**, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, Colegiado nº 40.065, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que por Diligencia de Ordenación de fecha 21 de febrero de 2022 se emplaza a esta parte para que en el plazo de veinte días formalice la demanda, por lo que, dentro del plazo conferido venimos a formalizar **DEMANDA** con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

HECHOS

PRIMERO.- Que, a día 23 de Marzo de 2021, el recurrente solicitó, al amparo del Art. 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, a la Ministra de Trabajo que “promueva la revisión de la legislación actual para el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Profesionales (...) equivalente al sistema de Salario Mínimo Interprofesional (en adelante, SMI), por considerar que la actual situación no se ajusta a derecho, y más concretamente, incumple los Art 14 y 35 de la Constitución Española, así como la legislación básica de la Unión Europea y su Carta de los Derechos Sociales Fundamentales”

Este documento, figura en el Expediente Administrativo como Doc. 1. Solicitud presentada por Ricardo Alvira Baeza (pág. 1-6), por lo que se remite a dicho expediente para el detalle de su argumentación (si bien se reproduce en gran medida en el Fundamento de Derecho Primero).

SEGUNDO.- Que, a día 29 de Marzo de 2021, el recurrente recibió una notificación de “remisión de escrito por incompetencia” mediante la cual, la Secretaria General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se inhibía de contestar la solicitud.

La citada Secretaria afirmó que “la competencia para conocer de dicha petición corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en virtud del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero; por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital”

Este documento, figura en el Expediente Administrativo como Doc. 2. Oficio de remisión al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (pág. 7), por lo que se remite a dicho expediente para el detalle de su contenido.

TERCERO.- Que ante la ausencia de respuesta posterior por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a día 23 de junio, se produce la desestimación presunta de la solicitud por la vía del silencio administrativo.

Que, ante esta inacción de la administración, el demandante decide acudir a la vía contenciosa para solicitar el amparo y protección de su derecho fundamental de petición (Art 29 CE), interponiendo recurso ante esta Sala con fecha 12 de octubre de 2021.

CUARTO.- Que cuatro meses más tarde de interpuesto el recurso, y una vez requerida en la vía judicial, la Dirección General de Política Económica (DGPOLECO) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha contestado la solicitud con fecha 12 de febrero de 2022, es decir, casi un año después de realizada la solicitud.

Este documento, figura en el Expediente Administrativo como Doc. 3. Informe sobre la solicitud de D. Ricardo Alvira Baeza en materia de honorarios profesionales (pág. 8-11), por lo que se remite a dicho expediente para su contenido concreto.

Mediante dicha contestación, la DGPOLECO rechaza la petición del demandante, alegando fundamentalmente motivos de “racionalidad económica” y de “defensa de la competencia empresarial”.

QUINTO.- Que la respuesta proporcionada por la Administración no se ajusta a derecho.

Los hechos Primero al Tercero descritos, llevan al demandante a interponer el presente recurso contencioso, durante el cual se ha producido el hecho Cuarto (la resolución expresa por parte de la DGPOLECO), y dado la inadecuación a derecho de la respuesta proporcionada por la DGPOLECO, el demandante decide formalizar la presente Demanda, que se basa en los siguientes;

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Competencia.- La competencia para conocer del recurso corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional según lo dispuesto en el artículo 11.1 de la LJCA.

II.- Legitimación.- La tiene activa mi representado conforme al artículo 19.1 apartado a) de la Ley 13 de julio de 1.998, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, por tener interés directo en este procedimiento.

La tiene pasiva la administración demandada a tenor del artículo 21.1 apartado a) de la misma norma legal, por ser la Administración de la que proviene el acto al que se refiere el presente recurso.

III.- Plazo de formulación de la demanda.- Se ha respetado lo establecido en la LJCA respecto al plazo para formular demanda.

IV.- Postulación- La parte actora actúa representado por Procurador de los Tribunales y dirigida por Abogado en ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

V.- Impugnabilidad del acto recurrido- Resulta impugnable el acto recurrido, en virtud del artículo 25.1 de la norma reguladora de esta jurisdicción, por tratarse de acto que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente es impugnado conforme al Artículo 24.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común por tratarse de silencio administrativo negativo, al decir, el precitado artículo; “El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.”

VI.- Costas.- En lo relativo a la imposición de costas, es de aplicación el artículo 139.1 de la LJCA. Caso de oponerse al presente recurso, debe estimarse que la Administración actúa con mala fe o temeridad, por lo que deberán imponerse las costas del presente proceso a la Administración demandada.

Es relevante destacar que la inactividad de la administración, al no dar acuse de recibo ni resolver la petición realizada, implica la estimación del recurso, más allá del pronunciamiento sobre el fondo, por lo que en ningún caso procede la imposición de costas al demandante (STS 1345/2019):

“tomando en cuenta todo lo anterior y que el derecho fundamental que aquí está en liza no es un derecho menor (...) el criterio de esta Sala es que (...) se debe estimar el recurso al constatarse que se ha producido una vulneración del contenido esencial de este derecho fundamental, pues la Administración destinataria de la petición (...) ni acusó recibo de ésta ni resolvió expresamente sobre la misma, en sentido favorable o desfavorable, hasta pasados casi siete meses desde que tuvo entrada en aquélla y una vez ya se había interpuesto por aquél el correspondiente recurso en vía judicial. Entendemos, por tanto, que la vulneración del plazo debe comportar, per se, la estimación del recurso por tratarse de un derecho fundamental.”

VII.- Fondo del asunto.

La Resolución Presunta de 23 de junio de 2021 del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como la Resolución Expresa de fecha de 12 de febrero de 2022, no se ajustan al ordenamiento jurídico vigente, lo que detallamos a continuación:

PRIMERO.- A modo preliminar se reproducen los fundamentos jurídicos incluidos en la Solicitud realizada a la Ministra de Trabajo, los cuales esta parte considera no han sido refutados conforme a derecho por la DGPOLECO, añadiendo pequeños comentarios y correcciones que clarifican o sustentan las afirmaciones realizadas en la Solicitud donde resulta procedente.

PRIMERO. A.- En el año 1997, el Gobierno de España eliminó la prerrogativa de los Colegios Profesionales, de fijar unos honorarios mínimos para la prestación de servicios por parte de los profesionales. Esta prohibición, se detalló en la *Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales*, en la cual se fundamentó la decisión en el objetivo de “*modificar determinados aspectos [que] limitan la competencia, introduciendo rigideces difícilmente justificables en una economía desarrollada*”

Concretamente, la prohibición se plasmó en el Art 5.Cinco.ñ, donde se consigna que los honorarios mínimos que establecen los Colegios profesionales, tienen “*carácter meramente orientativo*”.

Así mismo, como acertadamente apunta la DGPOLECO, “*la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (...) introdujo la prohibición de que los Colegios Profesionales puedan establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales (con la única excepción de la elaboración de criterios orientativos para la tasación de costas y la jura de cuentas de los abogados).*”

Sin embargo, el transcurso de los años ha mostrado que la eliminación de los honorarios mínimos profesionales no ha mostrado proporcionalidad respecto a los objetivos buscados.

En este sentido, es relevante revisar la caracterización de la ‘proporcionalidad’ en la Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, en su Artículo 7. *Proporcionalidad* dice:

“1. Los Estados miembros velarán por que sus nuevas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que restringen el acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio, y las modificaciones que realizan a disposiciones existentes sean necesarias y adecuadas para garantizar la consecución del objetivo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo.

2. f) el efecto de las disposiciones nuevas o modificadas, cuando se combina con otras disposiciones que restringen el acceso a la profesión, o su ejercicio, y en

particular el modo en que las disposiciones nuevas o modificadas combinadas con otros requisitos contribuyen a alcanzar el mismo objetivo de interés público, y si son necesarias para ello.

3. A efectos del apartado 2, párrafo primero, letra f), los Estados miembros evaluarán el efecto probable de las disposiciones nuevas o modificadas en combinación con uno o más requisitos, teniendo en cuenta que dichos efectos pueden ser tanto positivos como negativos, y en especial los siguientes:

k) requisitos en cuanto a tarifas mínimas”

Y es importante destacar que la desregulación tarifaria ha mostrado ya importantes efectos negativos en el ejercicio de las diferentes profesionales, y en especial, en la de los Arquitectos, colectivo al que pertenece mi representado.

Como señala el Estudio económico del *Architects’ Council of Europe* (en adelante, ACE) del año 2018 “[n]o se entiende por qué algunas autoridades de competencia están interesadas en introducir más competencia en un mercado completamente atomizado (el extremo opuesto a cualquier tipo de oligopolio o monopolio) donde los operadores económicos (es decir, los profesionales) carecen completamente de la fuerza para imponer sus intereses allí donde hay un nivel muy alto de competencia precisamente por esa razón, y donde los profesionales muy a menudo están sometidos a la fuerza por sus clientes (el Estado y las grandes empresas) y obligados a presentar ofertas que reducen sus márgenes de beneficios al mínimo.”

Baste, para tener una imagen de la gran atomización de las firmas en el sector de la arquitectura en España, la revisión de los datos sobre el tamaño de dichas firmas que proporciona el ‘Informe sobre el Estado de la Práctica de la Arquitectura en Europa’ en el año 2020, realizado por el *Architects’ Council of Europe* (ACE).

	TAMAÑO (EN NUMERO DE PERSONAS) DE LAS FIRMAS DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA							TOTAL FIRMAS
	1 p.	2 p.	3 a 5 p.	6-10 p.	11-30 p.	31-50 p.	+ de 50 p.	
ESPAÑA	4.386	2.207	1.429	502	39	3	1	8.567

Fuente: Informe del *Architects’ Council of Europe*, ACE año 2020, página 38

Se adjunta a modo acreditativo como **Doc.-Num.-01 Estudio del Sector de la Arquitectura en Europa en el año 2020 realizado por el Consejo de Arquitectos de Europa**. El Estudio está en idioma inglés, habiéndose incluido en el Escrito de Demanda la traducción privada al español (realizada al amparo del Art. 144 de la Ley Enjuiciamiento Civil) de las partes relevantes.

Se observa por tanto la elevada fragmentación del sector, que implica una reducida capacidad de negociación de los honorarios por los profesionales, y por tanto, una elevada fuerza de los clientes en la determinación de dichos honorarios.

PRIMERO. B.- Que la prohibición de los Honorarios Mínimos profesionales ha situado a los trabajadores autónomos en una situación de inferioridad frente a los trabajadores asalariados por una mera cuestión coyuntural: el tipo de contrato bajo el cual ejercen su profesión. Es decir, que la actual prohibición de los Honorarios Mínimos profesionales, constituye un factor de discriminación contra los autónomos, al posibilitar su trabajo en condiciones de inferioridad frente a los asalariados, algo que se hace especialmente crítico en situaciones de crisis económica y elevada competencia entre profesionales, incumpliendo así el Art 14 de la Constitución Española.

Resulta relevante recordar lo que ha afirmado al respecto del Art 14 CE el Tribunal Constitucional (STC 90/1989):

"el artículo 14 CE prohíbe, por una parte, que se dé un tratamiento desigual tanto en las previsiones normativas, como en su aplicación concreta, por un poder público, a quienes se encuentren en situaciones esencialmente similares, y, por otra, que si se introducen elementos de diferenciación para justificar tratamientos distintos, esos elementos han de ser razonables y no constituir una excusa o pretexto para producir, de hecho, un tratamiento arbitrariamente desigual, y, por tanto, discriminatorio".

Ya se ha indicado anteriormente que la propia Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales, mediante la cual se eliminaron los Honorarios Mínimos profesionales (los honorarios superiores a los mínimos eran legales con anterioridad a dicha ley, y siguieron siéndolo con posterioridad a la misma), fundamentó la decisión en el objetivo de *"modificar determinados aspectos [que] limitan la competencia, introduciendo rigideces difícilmente justificables en una economía desarrollada"*

Sin embargo, no existe ningún motivo por el cual los profesionales deban realizar esta competencia trabajando por debajo de unas tarifas mínimas. Lo contrario, nos llevaría a prohibir entonces el Salario Mínimo Interprofesional (en adelante SMI), alegando que los trabajadores deben concurrir a los puestos de trabajo en las empresas en régimen de "libre competencia", y por tanto, pueden reducir sus peticiones salariales a cantidades inferiores al coste de la vida, si con ello se fomenta la competencia.

Por tanto, al eliminar la remuneración mínima en el trabajo profesional autónomo, y permitir que dicho trabajo se realice en condiciones de remuneración inferior al SMI o el convenio laboral correspondiente (que serían la remuneración mínima si se realizara al amparo de un contrato laboral), la ley 7/1997 vulneró el Art 14 CE, al establecer condiciones de trabajo diferentes para personas que pueden realizar un mismo trabajo simplemente por una cuestión coyuntural; el tipo de contrato bajo el cual realizan dicho trabajo, y que no se relacionan por tanto ni con la calidad ni con el tipo de trabajo realizado.

Es además relevante destacar que, de los escasos datos disponibles, se deduce que efectivamente, en el sector de la Arquitectura, en la actualidad se ha alcanzado una

situación en la que los ingresos anuales de las personas que ejercen su profesión en la modalidad autónoma¹ son inferiores a los de las personas que ejercen su profesión en la modalidad asalariada. Baste, como ejemplo los datos que incluye el antes referido estudio del Consejo de Arquitectos de Europa (ACE):

Mediana de ingresos antes de impuestos según tipo/puesto de trabajo, ajustado según Paridad de Poder Adquisitivo, de los arquitectos en España en 2020		
Sector	Puesto	Ingreso anual (en PPA)
Asalariados Sector Publico	Otros empleos públicos	54.171 €
	Todos los empleos públicos	48.754 €
	Puestos Administración Local/ Central	44.962 €
Asalariados Sector Privado	Director Único / Socios/ Directores / Altos Cargos	32.503 €
	Empresas Privadas	28.711 €
	Empleados firmas privadas	27.086 €
Trabajadores Autónomos		24.377 €
Fuente: Informe del Architects' Council of Europe, ACE para el año 2020, página 55 (se ha anexado al Escrito de Demanda como Doc. Num-01)		

Puede apreciarse en la tabla anterior, que el Ingreso Mediano anual de los Arquitectos que ejercieron su profesión en el año 2020 en España en la modalidad “autónomo”, es inferior al Ingreso Mediano de los que ejercieron la profesión de Arquitecto en cualquier otra modalidad. Concretamente, según los datos que aporta ACE, el ingreso mediano de los autónomos es de 24.377 €, frente al ingreso mediano de los que ejercen la profesión de arquitecto en empresas privadas, que asciende a 28.711€, y en empresas públicas es superior en todo caso a 44.962 €.

Es más, la cifra de 24.377 €, es sensiblemente inferior al Salario de Convenio del año 2020 que fue de 26.115,34 € según establece la *Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos*². Es decir, que incluso la mediana de ingresos de los profesionales autónomos (no digamos ya el valor inferior de ingresos), es sensiblemente inferior al Salario de Convenio.

Se adjunta a modo acreditativo como **Doc.-Num.-02 Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.** La tabla salarial figura en Anexo I, pagina 27.

¹ Es relevante destacar además, que muchas personas ejercen su profesión en la modalidad de trabajo autónomo, no como el resultado de una elección personal, sino con frecuencia como única opción accesible, al ver restringido su acceso al mercado laboral por diversos motivos (p. ej., a partir de cierta edad).

² La cifra del Salario de convenio para el “Nivel 1, Licenciados y Titulados 2.º y 3.er Ciclo Universitario y Analista”, se calcula tomando como base el valor en la Tabla Salarial del Anexo I, y multiplicándolo por 100,75% (una vez para el salario de convenio de 2019, y dos veces para el salario de convenio de 2020, según establece el Art 33).

Por tanto, la infracción del Art 14 CE que se enuncia no es una mera argumentación teórica en base a una posibilidad, sino una realidad palpable y constatable, que no solo es sentida por todos los arquitectos que, con grandes dificultades económicas, ejercemos la profesión como autónomos, sino que es además confirmada por los datos disponibles. La no existencia de Honorarios Mínimos, que deberían ser Equivalentes al superior resultante de comparar el SMI con los Salarios de Convenio genera, por razones coyunturales, una discriminación que vulnera el Art 14 CE, hacia las personas que ejercemos nuestra profesión de arquitecto en la modalidad de trabajo autónomo.

PRIMERO. C.- Que el establecimiento del *Salario Mínimo Interprofesional*, SMI se hizo con el objetivo de satisfacer el Art 35 de la Constitución Española, que afirma que:

“1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.”

Es decir, el Art 35 de la Constitución Española no solo afirma el derecho de todos los españoles a trabajar; también afirma el derecho a que dicho trabajo les proporcione una remuneración suficiente para la vida.

Es relevante que desde su aparición en la legislación española, el SMI, ha estado vinculado precisamente al establecimiento de la compensación, a quien desempeña el trabajo, de una cantidad suficiente para vivir, y ha tenido vocación de extenderse para proporcionar protección al conjunto de los trabajadores españoles (ver por ejemplo, preámbulo en Decreto 55/1963, de 17 de enero sobre establecimiento de salarios mínimos...).

Es también relevante que el legislativo ha destacado ya desde los inicios de la regulación del SMI, que los ingresos de los trabajadores deben ser iguales o superiores a la cifra superior resultante de comparar el SMI con los Salarios de Convenio (ver p. ej. Decreto 55/1963, de 17 de enero, Art. Segundo).

Es, además preciso destacar, los importantes objetivos sociales y económicos que la actual Ministra de Trabajo y Economía Social, con el apoyo del Consejo de Ministros, ha asignado al SMI en España. Concretamente, en el preámbulo del *Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020*, se explicitan los siguientes objetivos Sociales, macroeconómicos y de sostenibilidad del Salario Mínimo Interprofesional:

“hacer efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso, en

línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores (...) el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo, y al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad.”

Continúa el RD 231/2020, afirmando que “*el salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios*”.

Es más, los Poderes Ejecutivo y Legislativo han alcanzado un acuerdo en cuanto al carácter del SMI como salario que constituye el nivel inferior (es decir, el suelo) de suficiencia, formalizando así la vinculación directa entre el SMI y el derecho a la vida, en el *Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre* (cuyo objetivo fue precisamente, desarrollar el Art 35 de la Constitución Española). La caracterización del SMI en dicho Estatuto lo hace equiparable con la remuneración mínima para una vida digna, al afirmar en su Art 27.2:

“El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable”

Es evidente, que esta naturaleza de ser inembargable, solo puede justificarse porque los Poderes Ejecutivo y Legislativo han primado el Derecho a que el trabajo permita una vida digna, frente a otros derechos y deberes de los ciudadanos, como por ejemplo, su responsabilidad en el sostenimiento de los gastos del Estado (Art 31 CE), que solo comienza a partir del momento en que son capaces de sostener una vida digna para ellos y para su familia.

PRIMERO. D.- Que de los tres fundamentos anteriores, se deduce con total claridad que la actual prohibición de la existencia de Honorarios Mínimos profesionales vulnera tanto la Constitución Española, como la legislación básica y Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea.

Concretamente, el cumplimiento de los Arts. 14 y 35 CE, implica que debería existir un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes (HME) a la cifra superior resultante de comparar el SMI y los Salarios de Convenio, que impidieran que las personas que ejercemos nuestra profesión en la modalidad de trabajador autónomo nos veamos con frecuencia obligados a recibir, por nuestro trabajo, ingresos inferiores a los que re-

ciben, por el mismo trabajo, las personas que lo ejercen en la modalidad de trabajador asalariado³.

SEGUNDO.- Que los fundamentos de derecho anteriores, han sido negados por la DGPOLECO en su respuesta, con argumentos que no se ajustan a la legislación vigente ni a su interpretación tal como ha establecido la jurisprudencia

La DGPOLECO sitúa como eje fundamental de su argumentación para resolver negativamente la preservación de la “libertad de Empresa (Art 38 de la CE)”.

Cita en este sentido la DGPOLECO dos Informes de la Comisión Nacional de la Competencia En primer lugar, la DGPOLECO cita el “Informe sobre el sector de servicios profesionales y Colegios Profesionales”:

“[en la] Decisión 2005/8 de la Comisión Europea, por la que se condenó al Colegio de Arquitectos Belgas por la inclusión en sus normas deontológicas de baremos indicativos se afirmaba que:

(78) Conviene recordar, a título preliminar, la jurisprudencia constante según la cual la fijación de un precio, incluso si es simplemente indicativo o recomendado, afecta al juego de la competencia (...)

(99) La Comisión considera que el establecimiento del baremo (recomendado) de honorarios mínimos no puede ser considerado como necesario para garantizar el buen ejercicio de la profesión de arquitecto (...).”

Es relevante indicar al respecto del párrafo anterior, que en la Petición realizada por el anteriormente peticionario y ahora demandante, no se argumenta la necesidad de establecer baremos recomendados para garantizar la calidad del trabajo, sino para garantizar dos derechos fundamentales: el Derecho a la no discriminación (Art 14 CE) y el Derecho a que el trabajo permita satisfacer las propias necesidades y sustentar a una familia (Art 35 CE), siendo que la decisión 2005/8 de la Comisión Europea no hace referencia a ninguno de estos dos derechos fundamentales.

Además, es relevante indicar que la Legislación y Jurisprudencia Europea se ha actualizado en los últimos años, modificando los criterios recogidos en los Informes de la, anteriormente designada como CNC y actualmente designada como, CNMC, (lo que se revisa en apartados subsiguientes).

³ Resulta además relevante añadir, que la implantación de este sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes, carecería de efecto alguno en el caso de que los profesionales en la modalidad autónoma superen con sus ingresos a los profesionales equivalentes en la modalidad asalariado.

Adicionalmente, dentro del segundo informe de la CNC/CNMC citado por la DGPOLECO, el “Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios”, la DGPOLECO cita:

“Los honorarios (...) tienen un gran interés desde el punto de vista de la competencia. La libre fijación de precios, aspecto crucial para el correcto funcionamiento de la economía de mercado, debe ser la regla general para permitir que el sistema económico en general y los consumidores y usuarios en particular, obtengan los máximos beneficios de la competencia (...)

La libertad de precios da lugar a una intensificación de la competencia que fomenta la innovación y las mejoras en la calidad y variedad de los servicios prestados, así como una mejor asignación de recursos productivos que refuerza el crecimiento económico y la creación de empleo. Por el contrario, las tarifas fijas, mínimas, máximas u orientativas, además de restringir la capacidad de obtener los anteriores beneficios, privilegian injustificadamente a los profesionales ya instalados, en detrimento de los nuevos entrantes, lo que afecta especialmente a los profesionales jóvenes y a aquellos más emprendedores.

La fijación de honorarios es una de las prácticas más dañinas de la competencia, puesto que limita la capacidad de los profesionales de utilizar el precio como herramienta de diferenciación y competencia. Los honorarios fijos o mínimos, junto a la restricción de la oferta, llevan a que los precios se sitúen por encima de lo que resultaría de la libertad de oferta y demanda, con el consiguiente perjuicio para consumidores (...)”

Es relevante destacar que en la Petición no se ha solicitado el establecimiento de Honorarios Máximos, ni tan siquiera la libertad de los Colegios Profesionales de decidir de manera autónoma cuales deben ser los Honorarios Mínimos. Lo que se ha solicitado es que el Gobierno directamente, o indirectamente asignándolo a los Colegios de Arquitectos y supervisándolo posteriormente, establezca un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes al ingreso que recibiría el mismo trabajo realizado por la persona si lo hiciera en el marco de una empresa u organismo oficial, es decir, a la cifra superior resultante de la comparación entre el Salario Mínimo Interprofesional y el Salario de Convenio correspondiente.

Por tanto, al citar el segundo párrafo del anterior informe como respuesta a esta Solicitud, la DGPOLECO está afirmando que lo que no es aceptable para unos ciudadanos si es aceptable para otros. Concretamente, la DGPOLECO está afirmando que las personas que realizan su actividad en un marco laboral organizado por otras personas, si tienen derecho a que dicha actividad les permita satisfacer sus necesidades y sostener una familia. Según la DGPOLECO, estas personas no deben, por ley, poder ofrecer el ejercicio de su profesión por debajo de ciertos ingresos que les garanticen poder satisfacer sus necesidades y sostener a su familia.

Pero por el contrario, según la DGPOLECO las personas que realizan idéntica actividad en un marco laboral autoorganizado (autónomo), no deben tener derecho a que dicha actividad les permita satisfacer sus necesidades y sostener una familia. Según la DGPOLECO, una pieza fundamental en la capacidad de estas personas de atraer clientes, debe ser poder ofrecerles el ejercicio de su profesión por unos honorarios que podrían no permitirles ni satisfacer sus necesidades ni sostener a una familia.

Y en opinión de esta parte, no solo lo anterior implica un profundo incumplimiento de los preceptos de no discriminación (Art 14) y derecho a que el trabajo permita satisfacer las necesidades propias y sostener una familia (Art 35 CE), acercándonos a una justificación desde los propios Poderes Públicos españoles de la legitimidad de existencia de la clase de “trabajadores pobres” que se ha consolidado en las últimas dos décadas, sino que incluso nos acerca a lo que podríamos denominar “competencia desleal” entre trabajadores.

Así mismo, se aprecia una enorme minusvaloración de la capacidad de los profesionales españoles por parte de la DGPOLECO. ¿De verdad cree la DGPOLECO que los profesionales españoles no somos capaces de competir en base a una mejora continua de nuestros servicios e innovación, y no a base de tirar los precios por debajo del mínimo necesario para vivir?⁴

Por último, la DGPOLECO alega que “Tampoco se considera apropiado equiparar a todos los efectos el precio que una **empresa** cobra a sus clientes por sus servicios (...) con el salario que cobra un empleado.”

Con esta afirmación, la DGPOLECO parece sugerir que el profesional autónomo es antes ‘empresa’ que ‘persona’, afirmación con la que el demandante, no puede estar en mayor desacuerdo. No solo la legislación española ha definido un marco jurídico en el cual el profesional que ejerce su profesión como autónomo, está sujetos a todos los deberes y obligaciones de las personas, sino que además, los estudios muestran que casi 4 de cada 5 personas que ejercen su profesión en la modalidad autónoma, lo hacen de manera personal y sin trabajadores asalariados a su cargo⁵.

⁴ Es relevante destacar, que desde el año 1997 (fecha de la derogación de los honorarios mínimos profesionales), la carga de trabajo que implican muchas de las actividades propias del ejercicio de la arquitectura, se han incrementado notablemente. En parte debido al creciente número de criterios normativos que deben cumplir los proyectos (p. ej. elaboración Libro del Edificio; cumplimiento normativas del Código Técnico de la Edificación; diseño edificios de consumo de energía casi nulo;...) y la implementación de nuevas tecnologías (p. ej. aerotermia), implicando en ambos casos cálculos especializados que con frecuencia se deben subcontratar.

También por la creciente implantación de metodologías de trabajo 3D en BIM, que mejoran el proceso de diseño, facilitan la mayor comunicación arquitecto-cliente y proveen un mayor control de la calidad de las edificaciones construidas, pero requieren el uso de software de coste muy elevado y mayor cantidad de horas de trabajo. Todo ello ha implicado un importante desarrollo del ejercicio profesional en términos de innovación y conocimiento, pero lo hemos debido asumir los profesionales de la arquitectura de una forma cada vez más precaria, en gran parte debido a la percepción de unos honorarios profesionales cada vez más reducidos en términos de poder adquisitivo.

⁵ Concretamente, el III Estudio Nacional sobre el Autónomo (pág. 21) realizado por realizado por *Infoautónomos* junto a la *Universidad de Granada* en noviembre de 2019 (accesible en: <https://www.infoautonomos.com/estudio-nacional-autonomo/>), eleva esta cifra hasta el 76,9%.

En relación a esta conceptualización por parte de la DGPOLECO del profesional como ‘empresa’ (persona jurídica) antes que como ‘persona física’ (o ser humano, si se prefiere), es relevante también señalar que el Legislativo ha definido la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE como el “derecho [de los individuos] a desarrollar una actividad empresarial”⁶.

La libertad de empresa no es por tanto, como parece afirmar la DGPOLECO, un derecho de las empresas como personas jurídicas a establecer los precios que quieran, sino de las personas físicas a emprender actividades empresariales, y es evidente, que el contenido de dichos emprendimientos, debe estar limitado por los derechos inherentes a las personas.

En ningún modo es justificable en base al marco regulatorio vigente priorizar los medios (la libertad empresarial) sobre los fines (objetivos de interés general y derechos fundamentales). La libertad empresarial no es más que un “medio” para lograr unos “fines”, que son la consecución en el grado más elevado posible de los objetivos de interés general y derechos fundamentales de las personas. La DGPOLECO se sitúa fuera del ordenamiento jurídico español, y europeo, al situar los primeros sobre los últimos.

Es además relevante destacar que en el propio ordenamiento jurídico europeo, concretamente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, CDFUE (2010/C 83/02) incorporada al Tratado Constitutivo de la UE, encontramos el derecho a la libertad de empresa (Art 16 CDFUE, que se corresponde aprox. con el Art 38 CE), pero también, y definido anteriormente, el derecho a la libertad profesional y al trabajo (Art 15 CDFUE, que se corresponde aprox. con el Art 35 CE). Por tanto, en las cuestiones en que ambos derechos entren en conflicto, será necesario revisar la naturaleza del conflicto, y decidir cuál debe prevalecer en cada una de las áreas en conflicto.

A modo preliminar resulta totalmente significativo que la CDFUE agrupe la libertad profesional con el derecho al trabajo en el Art 15 y no sitúe a los profesionales conjuntamente con las empresas en el Art 16, destacando así la equivalencia entre la actividad profesional y el trabajo, es decir, la naturaleza esencial del profesional como persona que ejerce un trabajo y no como una empresa que vende servicios.

Pero también es significativo que el propio art 16, al definir la libertad de empresa, ya introduce limitaciones a esta libertad (limitaciones que no introduce al definir la libertad profesional) concretamente menciona que esta libertad debe ejercerse “de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales”. La Libertad de empresa es por tanto un derecho que nace limitado desde su origen, en una posición subordinada al resto del Derecho de la Unión.

Resulta también procedente destacar que la propia CDFUE, afirma en su *Artículo 53. Nivel de protección* “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá

⁶ Accesible en <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=38&tipo=2>

interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros.”

También en relación a esta cuestión, resulta conveniente recordar el propio título de la ***Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad***, que no deja dudas en cuanto a la naturaleza de los trabajadores autónomos como personas antes que de empresas, y por tanto, sujetos al precepto de no discriminación entre hombres y mujeres.

Esta Directiva, que emana de los propios Tratados Europeos y por tanto el Consejo la considera coherente con ellos (también con la libertad de empresa), afirma en el prólogo que:

“Considerando que, en lo referente a las personas que ejercen una actividad autónoma, así como a sus cónyuges que participan en dicha actividad, conviene proseguir la aplicación del principio de la igualdad de trato mediante disposiciones concretas destinadas a responder a la situación específica de dichas personas”.

Así mismo, la Directiva afirma que (Art.1):

“La presente Directiva va dirigida, de acuerdo con las disposiciones que siguen, a garantizar la aplicación, en los Estados miembros, del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma o que contribuyan al ejercicio de dicha actividad en aquellos aspectos que no estén cubiertos por las Directivas (') DO n° C 113 de 27. 4. 1984, p. 4. 76/207/CEE y 79/7/CEE.”

Continúa la Directiva (Art. 2a) afirmando que afecta a:

“a los trabajadores autónomos, a saber, a toda persona que ejerza en las condiciones previstas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los agricultores y los miembros de profesiones liberales”

Queda por tanto confirmado que los trabajadores autónomos también están sujetos al principio de no discriminación, y que los poderes públicos que deben garantizar este derecho, que se superpone al de libertad de (creación y gestión de) empresa. El trabajador autónomo es una persona, y la empresa es meramente una de las opciones, es decir,

un medio, a disposición de dicha persona, en el caso de que lo quiera utilizar para ejercer su profesión, es decir, un medio a través del cual ejercer su derecho al trabajo.

Por mayor claridad, se añade a continuación Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea, que sustenta la argumentación del demandante y refuta la argumentación de la DGPOLECO.

TERCERO. Sobre los límites de la libertad de Empresa en la legislación Europea, y la compatibilidad de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes.

Tercero. Uno.- Análisis de la legislación de la UE

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su Artículo 101 (antiguo artículo 81) define la “libertad de empresa” como:

“1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

- a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;*
- b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;*
- c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;*
- d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;*
- e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.*

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,*
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,*
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,*

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

- a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
- b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate”.

La revisión del texto muestra que **desde el propio Artículo 101 del TFUE en el que se define la libertad de empresa se establecen también límites a la misma; la libertad de empresa puede ser restringida para “mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico”.**

Se plantea una doble pregunta: ¿Cuáles son estos objetivos de mejorar la producción o la distribución de los productos y fomentar el progreso técnico y económico? ¿Son estos objetivos iguales, superiores o inferiores a los derechos de no discriminación (igualdad) y derecho al trabajo, cuya vulneración se ha argumentado en el escrito de demanda?

Y a modo preliminar, es posible contestar la segunda pregunta, los tres criterios enunciados en el Art 101 TFUE son inferiores en todo caso a los tres derechos anteriormente mencionados.

- Los principios de igualdad y no discriminación (Arts. 20, 21 y 23 CDFUE; y Art. 14 CE) no pueden en ningún caso verse cercenados ni para “mejorar la producción o la distribución de los productos [ni para] fomentar el progreso técnico o económico”.
- El derecho a la vida no puede en ningún caso verse cercenado ni para “mejorar la producción o la distribución de los productos [ni para] fomentar el progreso técnico o económico “.
- El derecho al trabajo y que nos permita satisfacer las propias necesidades y sostener a una familia (Arts. 15, 31 y 33 CDFUE; y Art 35 CE) no puede en ningún caso verse cercenado ni para “mejorar la producción o la distribución de los productos [ni para] fomentar el progreso técnico o económico “.

Por tanto, resulta evidente que el derecho a la libertad de empresa no puede ser la base que sustente la ruptura del principio de igualdad, ni que minore el derecho a la vida, ni el derecho a que el trabajo permita sostener una vida digna. Los propios textos constitutivos (CDFUE y CE) no dejan dudas al respecto.

Es, además, relevante destacar que la UE ya ha afirmado la compatibilidad del derecho a la libertad de Empresa, y el establecimiento de Honorarios Mínimos, siempre y cuando se justifique la necesidad y proporcionalidad de estos Honorarios Mínimos, en la *Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de*

2006 relativa a los servicios en el mercado interior. En la citada Directiva, se establece en primer lugar la calidad de los servicios, como un objetivo de interés general que limita la libertad de empresa. Concretamente en su Artículo 1. Objeto:

“1. En la presente Directiva se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios.”

Así mismo, en esta Directiva, se indica la posibilidad de establecer tarifas (u honorarios) mínimos a determinados servicios profesionales. Concretamente, en la Sección 2. Requisitos prohibidos o supeditados a evaluación, Artículo 15. Requisitos por evaluar

“2. Los Estados miembros examinarán si sus respectivos ordenamientos jurídicos supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al cumplimiento de los siguientes requisitos no discriminatorios: (...) g) tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar”

Indica el propio artículo en su apartado 3, que estas tarifas obligatorias mínimas deberían cumplir dos condiciones:

“3. Los Estados miembros comprobarán que los requisitos contemplados en el apartado 2 cumplan las condiciones siguientes:

b) necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general;

c) proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.”

Por tanto, la propia UE ya ha aceptado el establecimiento de tarifas obligatorias mínimas, y la primacía de este derecho sobre la libertad de empresa, si lo justifican cuestiones de interés general (como evidentemente, es la protección de los derechos fundamentales) y las tarifas presentan proporcionalidad en relación a los objetivos buscados.

Precisamente para aclarar la cuestión de la *Proporcionalidad*, ha venido a promulgarse la *DIRECTIVA (UE) 2018/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones*. Esta Directiva, afirma en su preámbulo:

“(17) Cuando el acceso a actividades por cuenta propia o ajena y su ejercicio estén supeditados al cumplimiento de determinados requisitos (...) es necesario garantizar que dichos requisitos estén justificados por objetivos de interés público (...) o por razones imperiosas de interés general, reconocidas como ta-

*les en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Asimismo, es necesario aclarar que, entre las razones imperiosas de interés general reconocidas por el Tribunal de Justicia, están (...) la protección del medio ambiente y del entorno urbano (...) la protección y conservación del patrimonio histórico y artístico nacional; los objetivos de política social (...). Según reiterada jurisprudencia, **las razones puramente económicas, como el impulso de la economía nacional en detrimento de las libertades fundamentales, y las razones puramente administrativas (...) no pueden constituir razones imperiosas de interés general** (...).”*

En primer lugar, el párrafo anterior confirma que varias de las tareas habituales de los arquitectos se encuentran entre razones necesarias por el interés general. Concretamente, “la protección del medio ambiente y del entorno urbano (...) la protección y conservación del patrimonio histórico y artístico nacional”. Es más, la propia jurisprudencia de la UE ha aceptado que la defensa de la calidad de la arquitectura, siempre y cuando el acceso a la profesión se halle regulado, ya sería suficiente justificación del establecimiento de honorarios mínimos (ver EU:C:2019:562 que se revisa en el Fundamento de Derecho Tercero. Dos).

Es relevante añadir, que la naturaleza de la calidad de la arquitectura como bien de interés general, ha sido recientemente destacada desde el propio legislativo y ejecutivo españoles, en el *Anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura*, tanto en su preámbulo como en los Arts. 1 y 3 (cuyo contenido se detalla al final del Fundamento de Derecho Tercero. Dos).

En segundo lugar, el párrafo de la Directiva (UE) 2018/958 también explicita que los objetivos de política social implican ‘necesidad’ en los términos requeridos en el Art 3.2 de la Directiva 2006/123/CE, para justificar el establecimiento de Honorarios Mínimos. Pero además, la Directiva explicita que las razones puramente económicas argumentadas por la DGPOLECO “no [son] razones imperiosas de interés general” (lo que recalca en el Art 6.3). Continúa la citada Directiva afirmando que:

“(28) La introducción de requisitos adicionales puede resultar adecuada para alcanzar los objetivos de interés público. El mero hecho de que su efecto individual o combinado deba valorarse no significa que los requisitos sean, de entrada, desproporcionados. (...) Los Estados miembros podrían estudiar la posibilidad de establecer requisitos en materia de tarifas fijas mínimas o máximas que deban cumplir los prestadores de servicios, en particular en relación con los servicios en los que ello resulte necesario para la aplicación efectiva del principio de reembolso de los gastos, en la medida en que dicha restricción sea proporcionada y, en caso necesario, se prevean excepciones a las tarifas obligatorias mínimas o máximas.”

Por tanto, la Directiva hace explícita la compatibilidad entre la existencia de honorarios mínimos, y la libertad de empresa, siempre y cuando esos honorarios mínimos están justificados por “objetivos de interés público”, como evidentemente son los Derechos Fundamentales ya señalados.

Es además relevante en la definición de Proporcionalidad que la Directiva (UE) 2018/958 (relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas disposiciones de profesiones) hace en su Artículo 7:

“1. Los Estados miembros velarán por que sus nuevas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que restringen el acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio, y las modificaciones que realizan a disposiciones existentes sean necesarias y adecuadas para garantizar la consecución del objetivo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo.”

Porque es precisamente lo que se ha solicitado en la Petición realizada a la Ministra. No se ha solicitado que los Profesionales puedan pactar precios arbitrariamente; lo que se ha solicitado es que se establezca un sistema de honorarios mínimos que sean equivalentes –i.e., que sean iguales en el mayor grado posible- al valor superior resultante de comparar el Salario Mínimo Interprofesional y los Salarios de Convenio, siendo ambos valores ya existentes (y acordados entre organizaciones de trabajadores y empresarios, al amparo del Art 28 CDFUE).

Es decir, se ha limitado la petición a la mínima -y estrictamente necesaria- modificación legal para eliminar la actual discriminación entre personas trabajadoras, y establecer la igualdad entre todos ellos.

Mientras que no establecer estos mínimos (i.e., preservar la situación actual) implica preservar la actual discriminación de los trabajadores autónomos frente a los asalariados, permitir el establecimiento de Honorarios Mínimos superiores a los salarios de convenio, implicaría -de facto- una desigualdad que favorecería a los trabajadores autónomos frente a los asalariados (amen de limitar la libertad de empresa injustificadamente-). Por ello, esta parte ha limitado su solicitud a la modificación estrictamente “necesaria y adecuada para garantizar la consecución del objetivo perseguido, y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlo”.

Así mismo, el Artículo 7 explicita en su apartado 3.k entre las posibles medidas a incorporar por los Estados miembros, el establecimiento de “k) requisitos en cuanto a tarifas fijas mínimas o máximas”, por tanto, la petición presentada, se enmarca plenamente en las posibilidades que abre la Directiva, y que son por tanto, compatibles con la libertad de empresa.

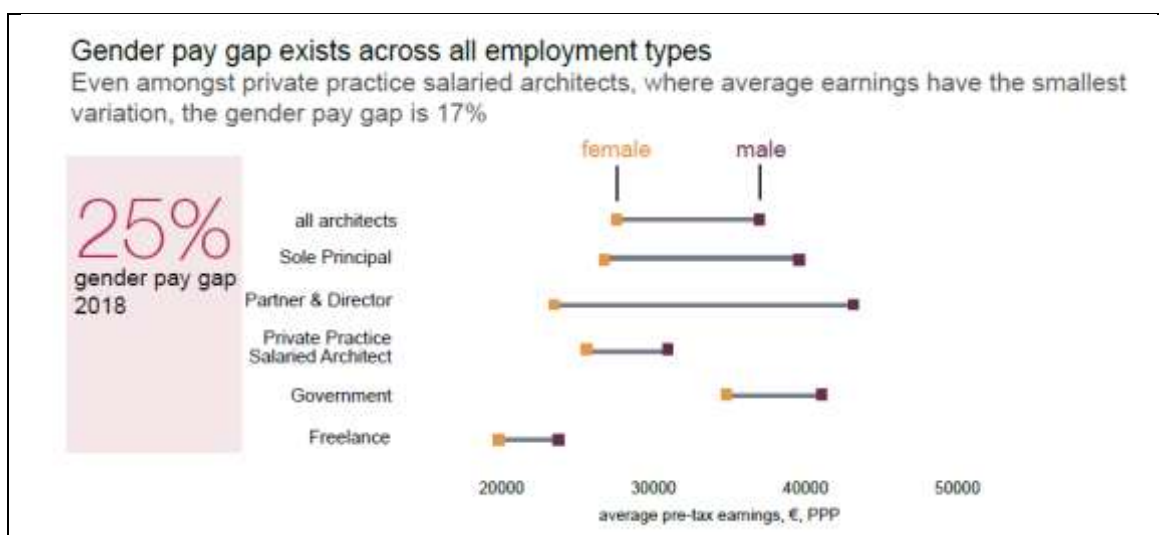
También resulta relevante la revisión de la “Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea”, COM(2020) 682 final 2020/0310 (COD) publicada a día 28.10.2020⁷.

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN>

Esta propuesta recalca que la mejora de la productividad de los Estados de la Unión Europea debe basarse en la innovación, y no en la reducción de los ingresos de los trabajadores, como que sugiere la DGPOLECO. Concretamente, la propuesta afirma que: “[l]a competencia en el mercado único debe basarse en la innovación, en la mejora de la productividad, así como en unos estándares sociales elevados.”

Afirma así mismo el documento que “[s]i los salarios mínimos se fijan en cuantías adecuadas, su protección garantiza una vida digna a los trabajadores, (...) La protección del salario mínimo también contribuye a la igualdad de género, ya que más mujeres que hombres perciben sueldos que se encuentran en torno al salario mínimo.”

Se pone de manifiesto por tanto otra vez la vinculación entre el sistema que limita los ingresos mínimos con los objetivos del Art 35 CE, pero también con los objetivos de igualdad establecidos en el Art 14 CE, por cuanto en la actualidad, es mayor el porcentaje de mujeres cuyos ingresos se sitúan en los tramos inferiores, y por tanto, serían más beneficiadas por la implementación de esta mejora: Honorarios Mínimos [profesionales] Equivalentes, especialmente, porque en niveles reducidos de ingresos la brecha entre hombres y mujeres es determinante para poder sustentar una vida digna.



Fuente Imagen: Estudio del Sector de la Arquitectura en Europa 2018, ACE (página 4). Traducción privada textos en imagen: Título superior: “La Brecha Retributiva de Género existe en todos los tipos de empleo. Incluso entre los arquitectos asalariados de pequeñas firmas privadas, donde los ingresos medios muestran la menor diferencia, la brecha retributiva de género es de 17%”. Otros términos tienen el siguiente significado: “Gender Pay Gap= Brecha Retributiva de Género; All architects = todos los arquitectos; Sole Principal=Administrador Único; Partner & Director =Socio y Director; Private Practice Salaried Architect = Arquitecto empleado en Firma Privada; Government=Arquitecto empleado del Gobierno; Freelance=Arquitecto autónomo; Female=mujer; male=hombre; Average pre-tax earnings, €, PPP= ingresos medios antes de impuestos, €, Paridad de Poder Adquisitivo.

Se adjunta a modo acreditativo como **Doc.-Num.-03 Estudio del Sector de la Arquitectura en Europa en el año 2018 realizado por el Consejo de Arquitectos de Europa.** El Estudio está en idioma inglés, habiéndose incluido en el

Escrito de Demanda la traducción privada al español (realizada al amparo del Art. 144 de la Ley Enjuiciamiento Civil) de las partes relevantes.

Todos los estudios económicos han mostrado que cuando no existen (o se eliminan) ingresos/salarios mínimos, el colectivo más perjudicado son las mujeres. Y el gráfico superior, extraído del estudio del ACE del Sector de la Arquitectura en Europa en el año 2018, muestra tanto el mucho menor ingreso de los trabajadores autónomos comparados con los de los arquitectos asalariados (entre un 25%-30% inferior), como el significado mucho más crítico que tiene la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en esta reducida cifra de ingresos. Y la Directiva 86/613/CEE confirma que en el marco de derechos de la UE la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho cuyo cumplimiento los poderes públicos deben también observar en relación a las personas que ejercen su profesión en la modalidad autónoma.

Continúa la citada propuesta COM (2020) 682 sobre el establecimiento de SMI europeo, que “[l]os objetivos de la Directiva propuesta están en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular con el derecho establecido en su artículo 31, apartado 1, sobre unas condiciones de trabajo justas y equitativas, que estipula que «todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad». La propuesta también facilita el ejercicio de los derechos reconocido en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que se refiere de manera específica a la igualdad entre mujeres y hombres, ya que contribuye a reducir la brecha salarial por razón de género.”

Por último, en relación a la interferencia con la libertad de empresa que ha manifestado la DGPOLECO, afirma el citado documento que “se prevé un impacto reducido en la competitividad a nivel agregado (pág. 12)”. Es decir, que referido a la competitividad alegada en la respuesta de la DGPOLECO, la UE afirma que apenas se ve afectada por el establecimiento de límites a los ingresos mínimos de los trabajadores.

Tercero. Dos.- Análisis de la Jurisprudencia de la UE.

Adicionalmente, es relevante revisar la **Jurisprudencia del TJUE, SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 4 de diciembre de 2014, «Competencia — Artículo 101 TFUE — Ámbito de aplicación material — Convenio colectivo — Disposición que establece unos honorarios mínimos para los prestadores autónomos de servicios — Concepto de “empresa” — Concepto de “trabajador”», en el asunto C-413/13.**

Esta sentencia aporta abundante luz en relación a la cuestión aquí discutida. En primer lugar, confirma la naturaleza subordinada del derecho a la libertad de empresa (Art 101 TFUE) respecto a los derechos y libertades de las personas. Solo así cabe entender la afirmación de la citada sentencia, cuando destaca que:

*“es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, **si bien determinados efectos restrictivos de la competencia son inherentes a los acuerdos colectivos celebrados entre las organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores, los objetivos de política social perseguidos por dichos acuerdos resultarían gravemente comprometidos si los interlocutores sociales estuvieran sujetos al artículo 101 TFUE**, apartado 1, en la búsqueda común de medidas destinadas a mejorar las condiciones de empleo y de trabajo (véanse las sentencias Albany, EU:C:1999:430 apartado 59; International Transport Workers' Federation y Finnish Seamen's Union, C-438/05, EU:C:2007:772, apartado 49, y 3F/Comisión, C-319/07 P, EU:C:2009:435, apartado 50)*

*Así pues, el Tribunal de Justicia tiene declarado que **los acuerdos celebrados en el marco de negociaciones colectivas que tienen lugar entre interlocutores sociales para el logro de dichos objetivos no deben considerarse comprendidos, en razón de su naturaleza y de su objeto, en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE**, apartado 1 (véanse las sentencias Albany, EU:C:1999:430 apartado 60; Brentjens', EU:C:1999:434, apartado 57; Drijvende Bokken, EU:C:1999:437, apartado 47; Pavlov y otros, C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, apartado 67; van der Woude, EU:C:2000:475, apartado 22, y AG2R Prévoyance, C-437/09, EU:C:2011:112, apartado 29).” [párrafos 22 y 23]*

Por tanto, según determina la sentencia **las medidas que fomentan la competencia quedan subordinadas a los objetivos de política social**, es decir, a los derechos sociales; precisamente lo que el demandante ha argumentado.

Concretamente, en la Petición realizada por el demandante, se ha explicado que **la prohibición de honorarios mínimos implica de iure, la desigualdad en materia de derechos sociales entre ciudadanos de la UE por cuestiones coyunturales y no sustantivas (puesto que el objeto producido –el trabajo realizado– es, como ya se ha explicado anteriormente, con frecuencia exactamente el mismo).**

Máxime porque **no se está pidiendo la autorización para que los Colegios Profesionales negocien o decreten por su cuenta Honorarios Mínimos** (posibilidad que está expresamente negada en la precitada sentencia), **sino para que la Administración o los Colegios (o mediante un procedimiento en que participen ambos), traduzcan los convenios ya aprobados en cuanto a Salarios Mínimos, en un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes (HME), que busquen la igualdad en los ingresos percibidos por unidad horaria dedicada al trabajo.**

Es decir, no se trata de que los Colegios se arroguen un poder negociador de honorarios mínimos; la negociación ya está realizada entre Gobierno, Patronal y Sindicatos. **Lo que se está pidiendo, es que no se excluya, por una condición meramente coyuntural de realizar el trabajo bajo contrato laboral o de autónomo (es decir, con la intermediación de una empresa o directamente con el cliente), a todo un colectivo de per-**

sonas, a los que se niega una protección y derechos sociales (que su trabajo les permita sustentar una vida personal digna y a sus familias) que se les ha reconocido ya a otros trabajadores.

No se está pidiendo que los Colegios profesionales decidan cual debe ser los ingresos que un trabajador percibe por su trabajo, sino que traduzcan, a partir del número de horas que requiere, como media, cada tipo de trabajo, en función de sus características singulares (y sobre la base de la abundante documentación existente, en gran parte elaborada desde los propios organismos públicos), los ya aprobados Salarios Mínimos Interprofesionales y de Convenio, en un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes que permita calcular los ingresos que debe generar su trabajo a los profesionales que los realizan, para que estas personas trabajadoras también sean amparadas por los objetivos sociales ya negociados entre Gobierno, Patronal y Sindicatos.

Por tanto, no puede producirse el alegado efecto “cartel” de empresas controlando los precios y limitando la competencia, porque no se realiza una negociación nueva. Los precios ya han sido fijados. La negociación de cuáles deben ser los ingresos netos por hora de trabajo ya ha sido realizada por otros agentes sociales (“organizaciones representativas de los empresarios y de los trabajadores”) cuya competencia en esta cuestión –por encima de la libertad de empresa - reconoce la precitada sentencia del TJUE.

Lo que se pide, es que a partir de dichos ingresos mínimos netos ya fijados, incrementando los costes específicos que tienen los trabajadores autónomos y que no tienen los asalariados (p. ej.: cuotas de la Seguridad Social, Seguros de Responsabilidad Civil -muy elevados en el caso de los Arquitectos-, Costes de Colegiación Obligatoria,) se determine un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes (HME).

Esta tarea la puede acometer el Ejecutivo, el Legislativo, los Colegios Profesionales, o ambos en algún procedimiento de tipo cooperativo, pero en ningún caso supone limitar la competencia entre trabajadores profesionales –que no empresas- en mayor grado de lo que el Salario de Convenio y SMI limitan la competencia entre trabajadores asalariados. Es evidente que la libertad de las empresas se incrementaría en gran medida si pudieran pagar a sus trabajadores salarios inferiores al SMI o a los de convenio, pero proteger los objetivos sociales lleva a imponer límites a esa libertad. Los mismos límites deben aplicar a los honorarios profesionales, para proteger también a las personas que ejercen su profesión en la modalidad autónoma.

Adicionalmente, la **Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de julio de 2019 en el asunto C-377/17 (ECLI:EU:C:2019:562)**, ha venido a ahondar en los límites de la libertad de empresa, definiendo el tipo de objetivos de interés general que permitirían limitar la libertad de empresa, y sostener un sistema de honorarios mínimos.

Mediante esta sentencia, el TJUE se pronuncia sobre el ajuste al principio de Libertad de Empresa de las tarifas de los arquitectos y los ingenieros que en Alemania se

rigen por el *Honorarordnung für Architekten und Ingenieure* (Reglamento sobre los Honorarios de Arquitectos e Ingenieros), de 10 de julio de 2013 (BGBl. I, p. 2276; en lo sucesivo, «HOAI»)⁸. La sentencia (EU:C:2019:562) afirma que

“(20) el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros (C-94/04 y C-202/04, EU:C:2006:758), estimó que la fijación de honorarios mínimos para los abogados constituía una restricción a la libre prestación de servicios, aun cuando el mercado se caracterizaba por la presencia de un número extremadamente elevado de abogados.”

Continúa la sentencia EU:C:2019:562 afirmando que el TJUE ha dictaminado repetidas veces que:

(38) las tarifas mínimas y máximas no constituyen una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación cuando el régimen que las establece se caracteriza por una flexibilidad que permite una cierta modulación de las tarifas en función de la naturaleza de las prestaciones realizadas” (EU:C:2006:758).

Por otra parte, si revisamos directamente la sentencia EU:C:2006:758 citada indirectamente en la sentencia anterior, afirma que:

“el hecho de que un Estado miembro encargue a una organización profesional integrada por abogados, como el CNF, la elaboración de un proyecto de baremo de honorarios, no parece que pueda demostrar, dadas las circunstancias de los asuntos principales, que dicho Estado haya retirado el carácter estatal al baremo finalmente adoptado, delegando en abogados la responsabilidad de tomar decisiones en la materia.

En efecto, aunque la normativa nacional controvertida en el procedimiento principal no contiene disposiciones de procedimiento ni normas materiales para garantizar, con una probabilidad razonable, que, al elaborar el proyecto de baremo, el CNF se comporte como una parte desgajada de la autoridad pública que persiga fines de interés general, no consta que el Estado italiano haya renunciado a ejercer su facultad de decidir en último término o a controlar la aplicación de dicho baremo (véase la sentencia Arduino, antes citada, apartados 39 y 40).

Por un lado, el CNF se limita a elaborar un proyecto de baremo que, como tal, carece de fuerza obligatoria. Si el Ministro de Justicia no lo aprueba, el proyec-

⁸ Es importante destacar que en Alemania, los HOAI establecen tanto tarifas mínimas como máximas para ciertos trabajos de arquitectura e ingeniería. Por el contrario la petición que se ha realizado se refiere únicamente a la necesidad de establecer tarifas mínimas, pero en ningún caso se ha solicitado limitar las tarifas máximas.

to de baremo no entra en vigor y se sigue aplicando el anterior baremo aprobado. Por ello, el Ministro puede obligar al CNF a modificar el proyecto. Además, dicho Ministro está asistido por dos órganos públicos, el Consiglio di Stato y el CIP, cuyo dictamen debe recabar antes de aprobar el baremo”

Concluye la sentencia EU:C:2006:758 afirmando que:

“Los artículos 10 CE, 81 CE y 82 CE no se oponen a que un Estado miembro adopte una medida normativa que, partiendo de un proyecto elaborado por un consejo de colegios de abogados como el Consiglio Nazionale Forense (Consejo nacional de colegios de abogados), aprueba un baremo que fija un límite mínimo para los honorarios de los miembros de la abogacía, baremo que, en principio, no admite excepciones ni por lo que respecta a las prestaciones reservadas a dichos miembros ni para prestaciones, como las de servicios extrajudiciales, que igualmente pueden ser realizadas por cualquier otro operador económico no sujeto a dicho baremo (...) Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal normativa, teniendo en cuenta sus modalidades concretas de aplicación, responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos.”

Por tanto, según ha dictaminado la Jurisprudencia Europea, el establecimiento de honorarios mínimos es aceptable si responde a objetivos de interés general, lo cual corresponde determinar al órgano jurisdiccional.

Volviendo al análisis de la sentencia **EU:C:2019:562**, procede destacar que dicha sentencia ha declarado :

“que los objetivos de garantizar la calidad de los trabajos y la protección de los consumidores han sido reconocidos por el Tribunal de Justicia como razones imperiosas de interés general (...) los objetivos de preservación del patrimonio arquitectónico y de construcción sostenible, estos pueden relacionarse con los objetivos más generales de preservación del patrimonio cultural e histórico, así como de protección del medio ambiente, que constituyen igualmente razones imperiosas de interés general [así mismo] debe señalarse que el considerando 40 de la Directiva 2006/123 confirma que la protección de los destinatarios de servicios, la protección del medio ambiente y los objetivos de política cultural constituyen razones imperiosas de interés general.”

Por tanto, incluso sin necesidad de entrar en las perspectivas de vulneración de derechos fundamentales ya indicadas, la jurisprudencia del TJUE confirma que garantizar la elevada calidad de los servicios de los arquitectos, se encuentra entre las causas de interés

general que permiten establecer honorarios mínimos que permitan a los profesionales desarrollar su actividad profesional en las condiciones debidas.

Es relevante destacar que el motivo por el cual la precitada sentencia (EU:C:2019:562) considera que el sistema de honorarios mínimos de Alemania no se ajusta a la búsqueda del interés general, es porque en Alemania no se establece ningún sistema de regulación para el acceso a la profesión, y que esta falta de regulación colisiona con el objetivo de garantizar la calidad (sentencia EU:C:2019:562, párrafos 90, 91 y 92).

En este sentido, es procedente destacar que, a diferencia de Alemania, en España si existe un control de acceso a la profesión de arquitecto que implica la superación de los estudios de arquitectura, y la posterior colegiación obligatoria y sujeción a un estricto código deontológico y control por parte de los Colegios de Arquitectos.

Por tanto, en España si se cumplen las condiciones que ha establecido la EU:C:2019:562 para considerar bien de interés general el ejercicio, profesional y regulado, de arquitectura de calidad, y por tanto, en España el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos profesionales, es perfectamente compatible con el derecho de la Unión Europea, incluso si se justificara únicamente desde la perspectiva del interés general que es mantener una elevada calidad de la arquitectura.

Para confirmar esta cualidad de interés general de los servicios de la arquitectura, es relevante además, revisar el *Anteproyecto de Ley de la Calidad de la Arquitectura, aprobado por el Consejo de Ministros en fecha de 18 de enero de 2022*⁹, cuyo prólogo afirma que

“debe considerarse que la Arquitectura es un bien de interés general que demanda la protección de los poderes públicos, a los que se exige que la preserven, la difundan y que pongan en marcha medidas de fomento que persigan el más alto nivel de calidad en todas sus realizaciones (...) el reconocimiento cada vez mayor a escala internacional de que la calidad de la Arquitectura como bien de interés general es un eje vertebrador y transformador para alcanzar un mayor bienestar y para ayudar a dar respuesta a muchos de los problemas existentes, iniciando políticas públicas ejemplarizantes que consigan desarrollarlos”

Esta naturaleza de la calidad de la arquitectura (campo profesional y de creación esencialmente ligado a la profesión de los arquitectos), como bien de interés general es destacada en el Art 1 del Anteproyecto:

“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. Esta Ley tiene por objeto proteger, impulsar y fomentar la calidad de la arquitectura como bien de interés general.

⁹ Accesible en <https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anteproyecto-de-ley-de-calidad-de-la-arquitectura>

2. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se entiende por Arquitectura el arte y la técnica de idear, diseñar, proyectar, construir, transformar y conservar, junto con la dirección y la ejecución de las obras correspondientes, edificios y espacios públicos para el desenvolvimiento de las actividades humanas. Todo ello en equilibrio armónico con su funcionalidad y utilidad, de acuerdo con valores culturales, sociales y estéticos y con la participación y la colaboración de las disciplinas profesionales necesarias para alcanzar toda su complejidad y a lo largo de todo su ciclo de vida.”

La declaración anterior se completa con el texto del Artículo 3:

“Artículo 3. Declaración de bien de interés general

1. La arquitectura constituye un bien de interés general, por su contribución a la creación de la identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar social, a la inclusión en la comunidad y a la salud, por su vinculación con la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, consumidoras y usuarias, por la relevancia que ostenta para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse a él, así como por su trascendencia económica.

2. En su condición de bien de interés general la arquitectura será objeto de protección, preservación e impulso, promoción y fomento por parte de todos los poderes públicos, cada uno de ellos en el ámbito de sus respectivas competencias y siempre en función de los valores concurrentes en la misma”

Por último, y enmarcado ya en la jurisprudencia española, resulta totalmente relevante destacar que el Tribunal Constitucional español también ha señalado la existencia de límites a la libertad empresarial¹⁰:

“el Tribunal Constitucional ha afirmado reiteradamente que el derecho a la libertad de empresa no es absoluto e incondicionado (por todas, STC 18/2011, de 3 de marzo). En efecto, el artículo 38 CE viene a establecer los límites dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. El mantenimiento de estos límites está asegurado por una doble garantía: por un lado, la reserva de ley y por otro, la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo del que ni siquiera el legislador puede disponer de un contenido esencial.

CUARTO. Sobre la definición del concepto de trabajador autónomo y la prevalencia de su caracterización como ‘persona física’ (es decir, como ser humano) que

¹⁰ Accesible en <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=38&tipo=2>

trabaja, y no como ‘persona jurídica’ (es decir, como empresa) que ofrece servicios, y el caso particular de los arquitectos, en la legislación española.

Que la revisión de la legislación española muestra una prevalencia, a la hora de definir sus deberes, de la caracterización de las personas que ejercen su profesión en la modalidad “autónoma” como personas físicas, y no como personas jurídicas. Esto muestra la contradicción que implicaría limitar sus derechos en base a su conceptualización como personas jurídicas, como propone la DGPOLECO.

A modo no exhaustivo, se detallan los siguientes ejemplos:

Cuarto. Uno. Caracterización del trabajador Autónomo desde la perspectiva de la Seguridad Social.

En toda la legislación relacionada con el sostenimiento de los gastos de la Seguridad Social, prevalece la conceptualización de las personas que ejercen su profesión en la modalidad “autónoma” como personas físicas, cuyas características inherentes a su naturaleza de persona física (nacionalidad, edad,...) son claves para determinar quienes están sujetos a qué regímenes de la Seguridad Social.

Por ejemplo, el *Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos*, afirma que:

“Artículo segundo. Concepto de trabajador por cuenta propia o autónomo.

Uno. A los efectos de este régimen especial, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.

Artículo tercero. Sujetos incluidos.

Estarán obligatoriamente incluidos en este Régimen Especial de la Seguridad Social los españoles mayores de dieciocho años, cualquiera que sea su sexo y su estado civil, que residen y ejerzan normalmente su actividad en el territorio nacional y se hallen incluidos en alguno de los apartados siguientes (...)”

Pero también en este marco legislativo se destaca el amparo de este grupo de trabajadores en el marco del Art 35.1. Por ejemplo, en el preámbulo de la *Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo*, se afirma que:

“las referencias normativas al [trabajo autónomo] se hallan dispersas a lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico (...) la Constitución, sin hacer una referencia expresa al trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos aplicables a los trabajadores autónomos. Así, el artículo 38 de la

Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado; el artículo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (...) la propia Constitución así lo determina cuando se emplea el término «españoles» en el artículo 35 o el de «ciudadanos» en el artículo 41, o cuando encomienda a los poderes públicos la ejecución de determinadas políticas, artículo 40, sin precisar que sus destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.”

Dicho de otra manera, el preámbulo afirma que tanto el Art 35 como el 38 son de aplicación a los trabajadores autónomos, pero limita la aplicación del Art 38 al cumplimiento de lo establecido en el Art 35.1, que no queda limitado a los “trabajadores por cuenta ajena”. Así mismo, esta ley insiste en la definición del trabajador autónomo como ‘persona física’ y no como ‘persona jurídica’ (artículo 1):

“La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.”

Continúa la citada ley afirmando en su Artículo 4, Derechos profesionales, el derecho de las personas que ejercen su profesión en la modalidad autónoma a las protecciones de no discriminación (Art 14 y 35 CE).

“1. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución Española y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España sobre la materia.

3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos tienen los siguientes derechos individuales:

a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Añade en el Artículo 6. Derecho a la no discriminación y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas:

“1. Los poderes públicos deben garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador autónomo.

2. Los poderes públicos y quienes contraten la actividad profesional de los trabajadores autónomos quedan sometidos a la prohibición de discriminación, tan-

to directa como indirecta, de dichos trabajadores, por los motivos señalados en el artículo 4.3.a) de la presente Ley. La prohibición de discriminación afectará tanto a la libre iniciativa económica y a la contratación, como a las condiciones del ejercicio profesional.

3. Cualquier trabajador autónomo (...) que considere lesionados sus derechos fundamentales o la concurrencia de un tratamiento discriminatorio podrán recabar la tutela del derecho ante el orden jurisdiccional competente (...) mediante un procedimiento sumario y preferente.”

Queda por tanto confirmado, que la legislación española otorga a las personas que ejercen su profesión en la modalidad de “trabajador autónomo”, los mismos derechos fundamentales y protecciones sociales que aplican a las personas físicas (Art 14 y 35), y por tanto, que los poderes públicos, deben vigilar su cumplimiento.

Para mayor abundamiento en el contenido del Art. 35, resulta conveniente revisar también su interpretación por parte del Congreso de los Diputados¹¹, que afirma:

“Conviene señalar que, aunque el art. 35 CE, a la hora de proclamar una remuneración suficiente, sólo contempla la prohibición de discriminación por razón de sexo, ello no supone que en el ámbito de las relaciones laborales la fórmula del art. 14 CE sufra una rotunda reducción. Antes al contrario, ya que, como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad en el ámbito laboral implica la eliminación de ‘cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales’; modalidades de discriminación que, bien se mencionan expresamente en el art. 35 CE, o se encuentran comprendidas dentro de la genérica fórmula con la que se cierra el art. 14 CE”

Por último, la anteriormente citada Ley 20/2007, afirma el derecho a un régimen de Seguridad Social, pero también la obligación de sustentarlo (Artículos 23, 24, y 25), en los cuales se recalca otra vez la prevalencia de los derechos vinculados a la naturaleza de persona física, y no jurídica, del trabajador autónomo:

“las personas que ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma tendrán derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”

Por tanto, la legislación española en materia de Seguridad Social confirma que el trabajador autónomo tiene los derechos fundamentales propios de las personas, es decir, que es una persona física y que mantiene dicha condición durante el ejercicio de su profesión, independientemente de si toma la decisión de fundar una empresa como medio para ejercer dicha profesión o no. Y la legislación tampoco deja dudas de que los derechos inherentes a la empresa se subordinan a los inherentes a la persona.

¹¹ Accesible en <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=35&tipo=2>

Para mayor abundamiento, se revisa a continuación la caracterización de varios tipos de profesionales, como personas físicas, y excluyendo su naturaleza de persona jurídica.

Cuarto. Dos. Caracterización de diferentes profesionales como personas físicas, y no como personas jurídicas.

Aunque los ejemplos son muchos, en aras de la brevedad, citamos solo dos ejemplos de profesionales autónomos a los cuales la legislación caracteriza de manera esencial como personas físicas y no jurídicas. Comenzamos por los profesionales de la arquitectura.

Cuarto. Dos. A. Caracterización del arquitecto como agente (persona física) que interviene en el proceso de edificación.

Esta prevalencia de los derechos y obligaciones vinculados a las personas físicas, y no a las personas jurídicas, se plasma con claridad en la *Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación*, en la cual se define la naturaleza de persona física de los principales puestos en el proceso edificatorio que ocupan los arquitectos.

Concretamente, en el *Capítulo III*, la *Ley 38/1999*, define los siguientes Agentes de la Edificación: el Promotor (Art. 9); el Proyectista (Art. 10); el Constructor (Art. 11); el Director de Obra (Art. 12); el Director de la Ejecución de la Obra (Art. 13); las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad de la Edificación (Art. 14); los Suministradores de Productos (Art. 15) y los Propietarios y los Usuarios (Art. 16).

Y es fundamental que al definir las características del Proyectista y Director de Obra, es decir, los dos papeles o roles que desempeñan principalmente los arquitectos en el proceso de edificación, la Ley 38/1999 explicita que estas funciones necesariamente deben ser asumidas por personas físicas y que posean la titulación habilitante:

“Artículo 10. 2. Son obligaciones del proyectista:

*a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante (...).
En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.”*

Artículo 12. 3. Son obligaciones del director de obra:

*a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante (...).
En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.”*

Es decir, según la ley 38/1999, una persona jurídica no puede asumir la redacción ni la dirección de la obra de un proyecto de arquitectura. Y es relevante destacar que son estas personas físicas que actúan como Proyectista y como Director de Obra, las que asumen las elevadas responsabilidades (patrimoniales y penales) establecidas en el Art 17

de dicha ley, respondiendo incluso de los defectos que pudiera haber en proyectos subcontratados a otros contratistas, durante un plazo que alcanza los 10 años.

Y esta parte se pregunta, ¿Cómo es posible que desde los poderes públicos españoles se argumente que los arquitectos somos empresas y no personas, cuando estos poderes públicos precisamente exigen nuestra naturaleza de persona física mediante la ley 38/1999 que nos obliga a aportar nuestra garantía personal y asumir unas elevadísimas responsabilidades, que en el caso de las patrimoniales afectan a todos nuestros bienes y se transmiten incluso a nuestros herederos legales, lo que no sucedería si fuéramos personas jurídicas?

No resulta aceptable que los poderes públicos españoles nos consideren ‘persona física’ para lo que nos impone unas cargas elevadísimas (empezando por la obligación de pagar cuotas de la Seguridad Social y contratar seguros de responsabilidad civil de coste muy elevado), y nos consideren ‘persona jurídica’ a la hora de excluarnos del beneficio social que implica la prohibición de trabajar por debajo de los salarios de convenio, negociados por sindicatos y organizaciones empresariales.

Es de destacar, que uno de los motivos principales para caracterizar las funciones del arquitecto como persona física y no como persona jurídica en los procesos de edificación, es precisamente que las personas jurídicas pueden ‘desaparecer’ (i.e., las empresas pueden ‘disolverse’) en el caso de que surjan problemas o se vean sometidas a procesos de reclamaciones elevadas, lo que de hecho ya ha sucedido en numerosas ocasiones. Por ello precisamente, la ley introduce la obligatoriedad de que exista una persona física (que no puede ‘desaparecer’), en el entendimiento de que esta asunción de responsabilidad con carácter ‘personal’ redundará en que el propio técnico tendrá mayor diligencia en la supervisión de la calidad de todo el proceso edificatorio, y por tanto, en una mayor calidad del proceso, generando así un beneficio para toda la sociedad.

Es evidente que el tratamiento que la ley 38/1999 hace de los deberes que comportan los papeles que desempeñan los arquitectos como agentes del proceso de edificación en su calidad de persona física, abundan en que en dicho ejercicio de su profesión les deben asistir también los derechos inherentes a las personas físicas, ya mencionados a lo largo de este escrito: no discriminación, igualdad, y derecho a que el trabajo permita satisfacer las propias necesidades y sostener a una familia.

Cuarto. Dos. B. Caracterización de otros profesionales como personas física.

De manera similar a la destacada para los arquitectos, encontramos en la legislación referencias similares a las destacadas en cuanto a la naturaleza de persona física de ciertos profesionales. Por ejemplo, referido a los abogados, el *Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española*, afirma en su preámbulo la necesidad de “promoción de medidas tendentes tanto a la concilia-

ción de la vida familiar y laboral como a la necesidad de avanzar, en sus instituciones, en la igualdad entre mujeres y hombres.”.

Se ha recalcado así específicamente desde el actual Poder Ejecutivo la naturaleza de persona física de estos profesionales y su derecho a la conciliación y no discriminación, incorporado al marco regulatorio en el Art. 97 que establece que:

“Artículo 97. Conciliación de la vida familiar y profesional. El Consejo General de la Abogacía Española promoverá la adopción por parte de los órganos y Administraciones competentes de cuantas acciones resulten precisas para hacer eficaz la conciliación de la vida familiar y profesional de todos los profesionales de la Abogacía [y] para conseguir una plena efectividad de los derechos reconocidos en la legislación orgánica sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres.”

A mayor abundamiento, el RD 135/2021 afirma la naturaleza de persona física de los abogados en su Artículo 1 y 9.

“Artículo 1. La Abogacía y sus principios rectores. 4. Los profesionales de la Abogacía deben ser personas de reconocida honorabilidad”

“Artículo 9. Requisitos para la colegiación. 1. Para colegiarse como profesional de la Abogacía deberán cumplirse los siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad y tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea (...) b) Poseer el título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía,”

Esta naturaleza de persona física se recalca en el propio Título I, en el cual se afirma que los profesionales de la abogacía son “Los Abogados y Abogadas”. Es más, en este artículo se destaca el control de acceso a la profesión, y su ejercicio (sometimiento a un código deontológico en el marco de un Colegio de Abogados):

“Artículo 4. Los profesionales de la Abogacía.

1. Son profesionales de la Abogacía quienes, estando en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de esta profesión, se encuentran incorporados a un Colegio de la Abogacía en calidad de ejercientes y se dedican de forma profesional al asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la defensa de derechos e intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía extrajudicial, judicial o arbitral.

2. Corresponde en exclusiva la denominación de abogada y abogado a quienes se encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía como ejercientes.”

Así mismo, esta naturaleza de persona física, y su importancia para el correcto control de ejercicio de la abogacía, se destaca en la existencia de un “expediente personal” para cada colegiado (Art 10. RD 135/2021), reforzándose la importancia de la cuidadosa

conducta y acatamiento del código deontológico por parte de los profesionales de la abogacía, cuyo derecho a ejercer pueden perder si no lo observan (Art 11 y 12. RD 135/2021).

Vemos por tanto que la legislación vigente, incluyendo diversos Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros, incluyendo a las actuales Ministras de Trabajo y Asuntos Económicos, confirma la naturaleza esencial de persona física, y no de persona jurídica, también de estos profesionales autónomos.

Es más, desde la perspectiva establecida en la EU:C:2019:562, el RD 135/2021 afirma el interés general de la función que ejercen los abogados, vinculado al derecho fundamental de tutela judicial efectiva (Art 6. RD 135/2021). Esta función social, unida al control del acceso a la profesión y fuerte sometimiento a un Código Deontológico (además de los ya referidos, ver p. ej. Art 35, Art 61 y Art 87.a) asumiendo una elevada responsabilidad que puede incluso implicar condenas penales (Art 125.i), ya implican que el ejercicio de la abogacía también entra dentro de los supuestos que admite la sentencia EU:C:2019:562 para la protección de la calidad del trabajo de la abogacía mediante el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos.

Por tanto, tampoco referido al ejercicio de la abogacía existe la restricción señalada por la DGPOLECO, y según el TJUE, el establecimiento de tarifas mínimas sería compatible con el Derecho a la Libertad de Empresa.

Cuarto. Tres. Sobre la asunción de la aplicabilidad del SMI a los trabajadores autónomos, por parte del Ejecutivo y Legislativo Español, y la primacía de la naturaleza de ‘persona’ y no ‘empresa’ del trabajador autónomo.

En tercer lugar, la revisión de las decisiones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en España, nos muestra que ambos poderes establecen con frecuencia tratamientos equivalentes en términos de beneficios y cargas entre ambos tipos de trabajadores, es decir, que ambos poderes comparten una visión en la que ambas figuras son en gran medida equivalentes.

Un primer texto que nos permite percibirlo, es la revisión de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que se aprueban (salvo imprevisto) anualmente, e incluyen las reglas para el cálculo de las cuotas de autónomos, y que suelen preservarse de año en año, simplemente actualizando los importes del SMI.

Como ejemplo, la *Ley de Presupuestos Generales del Estado 22/2013, de 23 de diciembre*, en su Art 128. (Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2014) establece las siguientes bases de cotización:

“Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social.

1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir de 1 de enero de 2014, en la cuantía de 3.597,00 euros mensuales.

2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, durante el año 2014, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario”.

Estas son las bases máxima y mínima que se aplican en general a todos los trabajadores, y también a los trabajadores autónomos, como se recoge en el apartado cinco:

“Cinco. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima, y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2014, los siguientes: 1 La base máxima de cotización será de 3.597,00 euros mensuales. La base mínima de cotización será de 875,70 euros mensuales.”

La comparación de las cifras muestra que para la determinación de la base máxima, la ley explicita la igualdad entre trabajadores asalariados y autónomos. Por otra parte, la comparación de las cifras evidencia que, en la determinación de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, el legislador ha buscado establecer (sin hacerlo explícito) la máxima igualdad posible con la base mínima de cotización para los trabajadores asalariados, tomando como referencia el SMI en cada momento, e incrementándolo en una sexta parte.

Concretamente, el SMI en 2014 era de 645,3€ en 14 pagas, es decir 9.034,2 €/año. Si lo dividimos entre 12 meses, resulta una cuantía de 752,85€/mes; calculamos la sexta parte (752,85/6) y obtenemos 125,48 €, y si lo sumamos a la cuantía mensual (752,85+125,48) resulta una base mínima para los trabajadores asalariados de 878,33 €. La cifra es un 0,3% superior, es decir, prácticamente idéntica a la base mínima de 875,70 €/mes para autónomos establecida por la Ley 22/2013¹².

Este mecanismo para calcular la base de cotización a la SS de los trabajadores ha sido preservado en la legislación posterior, siendo actualizado según los incrementos del

¹² Esto implica de manera tácita, que en base al principio de proporcionalidad en el sostenimiento de los gastos del Estado (Art 31 CE), el legislativo considera que el trabajador autónomo tiene al menos ingresos iguales o superiores al SMI. Es decir, el Legislativo asume de manera tácita la existencia de unos Honorarios Mínimos Equivalentes para el cálculo de la aportación de los autónomos en el sostenimiento de los gastos de la Seguridad Social.

SMI y coste de la vida (IPC), así en la *Ley de Presupuestos Generales del Estado 36/2014, de 26 de diciembre*, para el año 2015 se establecen las siguientes bases de cotización (art. 103): “Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos: En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2015, los siguientes: 1. La base máxima de cotización será de 3.606,00 euros mensuales. La base mínima de cotización será de 884,40 euros mensuales”, o en el *Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo*, vemos que la base mínima de cotización asciende a 944 €/mes aprox.

Además, más recientemente los actuales Poderes Ejecutivo y Legislativo, han acordado y explicitado esta relación de equivalencia entre trabajadores asalariados y autónomos para establecer las cuotas de la Seguridad Social en el RDL 02/2021. En efecto:

*“Así quedo decidido en el Real Decreto-ley 02/2021, de 26 de enero, en el que se estipuló [en su disposición transitoria cuarta] que "a partir del 1 de febrero de 2021 y mientras no se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2021 no será de aplicación lo previsto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre" (extraído de periódico Vozpopuli día 13 de octubre de 2021)*¹³.

Esa disposición transitoria del Real Decreto-ley 02/2021 establecía el incremento de la cotización de los autónomos a la Seguridad Social en el año 2021, y la vinculaba a la subida equivalente del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, mediante el RDL 02/2021, los actuales Poderes Ejecutivo y Legislativo han explicitado, por fin, en una ley su asunción de que el trabajador autónomo tiene ingresos anuales que igualan o superan el SMI, de lo contrario se le estaría discriminando, al hacerle pagar una cuota equivalente (casi exactamente igual) a la que paga un trabajador asalariado con SMI.

Y esta parte se pregunta, ¿en base a que supuesto legal justifica la DGPOLECO que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (dos de los poderes que, según establece el Art 9,2 CE deben procurar la igualdad entre ciudadanos) iguale a los Trabajadores Autónomos y Asalariados cuando se trata de calcular sus cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo que los trabajadores autónomos ingresan como mínimo el SMI, pero los diferencie cuando se trata de proteger sus ingresos mínimos por hora de trabajo realizado, excluyendo expresamente a los trabajadores autónomos de la protección que brinda el SMI y Salarios fijados en Convenio?

Los tres apartados anteriores, confirman que el marco regulatorio vigente en España muestra la asunción tacita por parte de los Poderes Públicos Ejecutivo y Legislativo, de una equivalencia entre trabajadores asalariados y autónomos a la hora de repartir las

¹³ Accesible en https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/subida-smi-autonomos.html

cargas, y la existencia de un SMI que al ser explícito para los trabajadores asalariados les genera cargas pero también les provee beneficios, pero un SMI tácito para los trabajadores autónomos, que al no ser explícito, les genera cargas, pero les excluye de los beneficios.

Igualmente podríamos seguir revisando numerosa legislación abundando en el paradigma anterior, lo que se omite por no extender excesivamente este escrito. No obstante baste como ejemplo señalar que el profesional autónomo está obligado a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no el Impuesto de Sociedades (es decir, el que pagan las personas jurídicas), siendo que los tipos impositivos de este último son mucho más reducidos.

¿En base a qué principio jurídico el Poder Ejecutivo y Legislativo español sostiene la igualdad entre individuos (i.e., trabajadores asalariados y autónomos) para establecer su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado (Seguridad Social, IRPF,...) pero la rompe a la hora de establecer su derecho a que su trabajo le permita satisfacer sus necesidades y sostener una familia, penalizando injustificadamente a las personas que ejercen su profesión en la modalidad autónoma?

QUINTO. En cuanto a la vulneración del Art 9.2 CE producida por la situación actual

Adicionalmente a los artículos 14 y 35 ya revisados, es relevante revisar el Art 9.2 CE, que afirma que

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Es evidente que la ausencia de Honorarios Mínimos para los profesionales, implica una desigualdad entre individuos/ciudadanos. Porque más allá de cuestiones subjetivas de catalogación entre profesionales autónomos y asalariados, ambos son ‘ciudadanos’, y el marco jurídico regulatorio tras la eliminación de los Honorarios Mínimos profesionales ha creado una diferenciación clara entre unos ciudadanos que no pueden trabajar por debajo de unos ingresos mínimos por hora, y otros ciudadanos que sí.

Y el problema, es que la elevadísima competencia existente en el mercado profesional, nos muestra que en la actualidad muchas personas –entre ellos el demandante– ejercemos nuestra profesión recibiendo ingresos por hora que pueden incluso llegar a ser la mitad del Salario Mínimo Interprofesional.

Es relevante también en relación al mandato constitucional contenido en el Art 35 CE, la STC 31/1984 de 7 de Marzo (BOE núm. 80, de 03 de abril de 1984), que afirma:

“un Estado social y democrático de derecho que propugna entre los valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (artículo 1.1 CE) y en el que se encomienda a todos los poderes públicos el promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (artículo 9.2 CE) ha de complementar aquel sistema de determinación del mínimo salarial estableciendo unos techos salariales mínimos que, respondiendo a aquellos valores de justicia e igualdad, den efectividad al también mandato constitucional contenido en el artículo 35.1”

Continúa la citada sentencia afirmando que:

“El principio de igualdad (artículo 14 CE) implica la eliminación en el conjunto de los factores y condiciones retributivos para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye igual valor, de cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales (...) El que el artículo 35.1 de la CE no especifique, a la hora de proclamar el derecho a una remuneración suficiente, más que la discriminación por razón de sexo no debe llevarnos a la idea de que en el campo particular de las relaciones laborales la fórmula del artículo 14 CE sufre una tan rotunda reducción”.

Y es evidente que cuando un arquitecto realiza un proyecto de una vivienda y posteriormente dirige la ejecución de la obra, este trabajo tiene *idéntico valor* en el supuesto de que el arquitecto lo realice directamente para la persona que va a habitar dicha vivienda, siendo esta persona la que abone los honorarios del arquitecto, o que lo realice con la intermediación de una empresa, siendo entonces la empresa la que abona el salario del arquitecto. El propio término “retribución” utilizado en la STC 31/1984 engloba tanto el concepto de salario como el de honorario.

Este igual valor tanto del objeto resultado de la actividad profesional del arquitecto como del valor del trabajo realizado es esencial al objeto que se discute, y completamente independiente de la “coyuntural y discrecional” diferente caracterización de ambos supuestos en la legislación vigente, que tiende a caracterizar la primera situación como Trabajo Autónomo y la segunda como Actividad Laboral.

Se trata por tanto de caracterizaciones coyunturales y discrecionales, relacionadas con cuestiones de organización ministerial y redacción de la legislación, pero que no pueden afectar en ningún caso a los derechos (y deberes) fundamentales inherentes a la igualdad esencial del acto y proceso realizado por el arquitecto, que es lo que se discute en el presente recurso.

Resulta también ilustrativo revisar al objeto de este apartado, la declaración de la actual Ministra de Trabajo al Periódico La Vanguardia el día 06/12/2021:

“Hablar de libertad e igualdad es, precisamente, hablar de salarios mínimos justos y salarios mínimos altos”, añadió [la ministra de trabajo], defendiendo que son un instrumento para el crecimiento inclusivo”¹⁴

Si como afirmó la ministra, hablar de libertad e igualdad es hablar de salarios mínimos justos, entonces esta parte no comprende porque la DGPOLECO sostiene que muchos ciudadanos que, con frecuencia por cuestiones ajenas a nuestra voluntad –por ejemplo, por mayor dificultad de ser contratado laboralmente por una empresa a partir de cierta edad-, realizamos el trabajo profesional dentro de la llamada categoría “autónoma” y no en la categoría “asalariada”, debemos quedar excluidos de esa libertad, igualdad, y crecimiento inclusivo.

Sirva como referencia, que el mismo artículo indica como umbrales de pobreza (que en un Estado que se autodenomine “del bienestar”, debería sin duda ser un mínimo) “el equivalente al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio, según la definición de la Confederación Europea de Sindicatos”, indicadores que se recomienda tener en cuenta a la hora de fijar los salarios mínimos.

Es además conveniente destacar el gran número de testimonios de profesionales (no solo arquitectos, también p. ej., abogados) que confirman que la elevada competencia les obliga a basar la obtención de clientes no en la calidad e innovación, sino en cobrar precios irrisorios, lo que precisamente les impide invertir para innovar. Baste, entre los numerosos testimonios publicados el del periódico El Independiente a día 19 de febrero de 2022: “[q]uienes trabajan por su cuenta tienen altas cargas económicas y están en una continua búsqueda de clientes en un ambiente en el que se tiran los precios”¹⁵.

Y esta parte se pregunta ¿De verdad consideran los Poderes Públicos españoles aceptable que exista un amplio grupo de ciudadanos que se vean obligados a trabajar muy por debajo de los salarios de convenio?

¿De verdad consideran los Poderes Públicos españoles que los trabajadores autónomos no merecemos ningún tipo de protección, ni debemos tener derecho a la desconexión ni a descansar los fines de semana (Art 31 CDFUE)?

Muchos profesionales no dejamos de trabajar los fines de semana, no porque no tengamos necesidad de descansar, sino porque la realidad de vernos obligados a trabajar cobrando honorarios irrisorios, con frecuencia muy por debajo incluso del SMI, hace que debamos multiplicar el número de horas trabajadas para lograr llegar a fin de mes y poder sostener, a duras penas, a nuestras familias.

¹⁴ Accesible en <https://www.lavanguardia.com/economia/20211206/7912737/ue-impulsa-salario-minimo-negociacion-colectiva-combatir-precariado-salarial.html>

¹⁵ Accesible en <https://www.elindependiente.com/espana/2022/02/19/el-drama-de-los-abogados-jovenes-menos-de-13-000-euros-anuales-y-jornadas-maratonianas-sin-desconexion/>

SEXTO. En cuanto al posible método de cálculo de los Honorarios Mínimos Equivalentes

Sin querer entrar a proponer como debería ser el método de cálculo para establecer un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes, esta parte si considera conveniente esbozar cual podría ser a grandes rasgos, un sistema así, para mostrar la factibilidad del mismo; es decir, para mostrar que nos encontramos frente a una tarea que puede realizarse de manera extremadamente sencilla.

Concretamente, para establecer la correspondencia entre Salarios de Convenio y Honorarios Mínimo, existen hoy día varias orientaciones de honorarios para proyectos técnicos publicadas por Organismos oficiales, que muestran que es posible realizar un cálculo suficientemente razonable e incluso podrían aprovecharse directamente.

Se adjunta a efectos acreditativos como **Doc. Núm. 04 la Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría [del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas], por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA.**

En la citada resolución, se incluyen cifras orientativas de honorarios para múltiples de los trabajos en el ámbito profesional de los arquitectos, cuyo método de cálculo podría aportar el citado Ministerio, para utilizarlo de guía para el establecimiento del sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes.

Hay que destacar que también ciertas asociaciones relacionadas con el mundo de la Arquitectura, como Asemas (empresa especializada en seguros de responsabilidad civil de arquitectos) han realizado numerosos estudios, llegando a establecer correspondencias muy precisas del esfuerzo en horas necesario para cada tipo de trabajo profesional de arquitectos¹⁶.

Estas estimaciones, que recogen los estudios realizados a lo largo de varias décadas, servirían para calcular un sistema de honorarios mínimos consistente con la realidad profesional, y que resultara equivalente, en el máximo grado posible, a los salarios mínimos (SMI o de Convenio) aplicables en el caso del ejercicio equivalente de la profesión en la modalidad asalariada.

Por último, hay que indicar que los Honorarios Mínimos profesionales Equivalentes, deben constituir tarifas mínimas que aplican a las actividades profesionales, independientemente de si éstas son realizadas directamente por personas físicas (trabajadores profesionales) o con la intermediación de personas jurídicas (sociedades profesionales,

¹⁶ Igualmente encontramos numerosas fuentes de información en otras muchas profesiones (p.ej., en el caso de los abogados, existen numerosas estimaciones de costes, realizadas para los servicios asociados a la Asistencia Jurídica Gratuita).

empresas...). Las personas jurídicas no deben poder ofrecer dichas actividades profesionales a un precio inferior porque constituiría una conducta colusoria en los términos definidos en la *Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia*, que prohíbe (Art 1.):

“La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros”

Es evidente que si las empresas no estuvieran sujetas a las tarifas que se deriven de estos Honorarios Mínimos Equivalentes, emergería una competencia desleal, por cuanto las empresas podrían ofrecer precios más reducidos a los consumidores, y el trabajador profesional pasaría a estar todavía más desprotegido que en la actualidad.

SÉPTIMO.- Que de todo lo anterior se deduce que la respuesta desestimatoria de la petición proporcionada por la DGPOLECO no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente en España.

Que en los apartados anteriores se ha mostrado que la citada respuesta no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, incumple derechos fundamentales, y es nula de pleno derecho, en los términos establecidos en el Art 47.1.a y f de la Ley 39/2015. Por tanto, nunca se ha producido, y el derecho fundamental de petición (art 29 CE) del demandante sigue en la actualidad vulnerado por la administración requerida.

Es procedente destacar que la jurisprudencia ha establecido que “el derecho de petición no se traduce en la necesidad de que su destinatario lo admita [pero] sí comprende la obligación de ese destinatario de tramitar la petición y observar en su eventual declaración de inadmisibilidad determinadas exigencias legales” (STS 4126/2021)

Y esta es la cuestión en la que yerra la contestación de la DGPOLECO, que si bien aparentemente responde la petición realizada, lo hace mediante una argumentación que no se ajusta a derecho, comprendiendo tanto la redacción de las leyes como las aclaraciones en su interpretación que constituye la Jurisprudencia.

Adicionalmente, es preciso destacar el Art 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas de la Ley 4/2001, que en su apartado 2 establece que:

“Artículo 11.2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.”

OCTAVO.- Que adicionalmente, a esta parte le quedan dudas acerca de cuál es el organismo del Estado competente para resolver sobre esta petición

Pese a que el RD 403/2020 establece entre las competencias de la DGPOLECO “[e]l estudio, análisis e iniciativa de propuestas de reforma de la regulación de las reservas de actividad, las profesiones reguladas y los colegios profesionales.” (Art 5.f), la argumentación y vulneración de derechos aportados por el demandante, aluden esencialmente a cuestiones de las cuales es competente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y no tanto a las cuestiones de las cuales es competente el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo este quizás el motivo del amplio desconocimiento de estas cuestiones en la respuesta de la DGPOLECO.

Para aclararlo, conviene revisar cuales son las competencias principales de cada Ministerio. Concretamente, según el RD 403/2020, Art. 1, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es:

“el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta, coordinación y ejecución de la política del Gobierno en materia económica, de apoyo a la empresa y de reformas para la mejora del crecimiento potencial y de la necesaria interlocución en estos asuntos con la Unión Europea y otros Organismos Económicos y Financieros Internacionales; así como de la política de telecomunicaciones y para la transformación digital, en particular impulsando la digitalización de las Administraciones Públicas. Igualmente le corresponde el establecimiento de las disposiciones y directrices necesarias para su funcionamiento, así como el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.”

Por otra parte, según el RD 499/2020, Art. 1, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, es:

“el Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de empleo, de relaciones laborales, de economía social y de responsabilidad social de las empresas”

Por tanto, el Ministerio de Asuntos Económicos se especializa más en funciones relativas a las empresas (personas jurídicas) y de política económica¹⁷, mientras que el Ministerio de Trabajo lo hace en relación a los trabajadores (personas físicas) y sus derechos en cuanto que son personas trabajadoras.

Por ello, una vez evidenciado la prevalencia de la naturaleza (y deberes y derechos asociados) de los profesionales autónomos como personas físicas que ejercen una actividad o trabajo, sobre la de personas jurídicas que ofrecen unos servicios, pero tam-

¹⁷ Es relevante recordar que según la Directiva (UE) 2018/958 (ya revisada en el fundamento de Derecho Tercero. Uno) “las razones puramente económicas (...) no pueden constituir razones imperiosas de interés general”.

bién evidenciada la interrelación en la legislación vigente entre el SMI y los ingresos de los autónomos, esta parte considera que el Ministerio de Trabajo y Economía Social resulta tanto o más competente/cualificado para informar/resolver sobre la cuestión que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo este precisamente el motivo por el cual la Petición fue dirigida desde un principio a la Ministra de Trabajo y no a la Ministra de Asuntos Económicos.

Adicionalmente, es relevante que la propia Real Academia Española, RAE destaca que cuando hablamos de personas que ejercen su actividad en la modalidad de autónomo, hablamos de Trabajo. Concretamente, según la RAE (2022), la definición de Trabajo es:

1. m. Acción y efecto de trabajar.

Y a su vez, la RAE define el término *Trabajar* como:

2. intr. Tener una ocupación remunerada en una empresa, una institución, etc. ¿Trabajas o estudias?

3. intr. Ejercer determinada profesión u oficio. Trabaja COMO periodista. Trabaja DE jardinero.

Por tanto, según la Real Academia Española “trabajar” es tanto “tener una ocupación remunerada en una empresa”, como “ejercer una profesión u oficio”. Según la RAE, trabajador es tanto el asalariado como el autónomo.

A mayor abundamiento, en el concepto de trabajo, resulta útil volver a revisar el RD 135/2021, Estatuto General de la Abogacía, que en su Artículo 5, define la función de abogados y abogadas como una forma de trabajo, según es definido por la Real Academia Española, concretamente:

“Artículo 5. Ámbito del ejercicio profesional. 1. El abogado y la abogada podrán ejercer su profesión”

Aporta todavía mayor luz, la revisión dentro del RD 135/2021, del *Título III. Formas de ejercicio profesional.* Este título explicita como formas de ejercer la profesión de la abogacía, tanto el “ejercicio de la Abogacía por cuenta propia” (Capítulo I. Arts. 35 y 36), como el ejercicio “por cuenta ajena en régimen laboral” (Capítulo II. Arts 37-39). Se despeja así cualquier duda de que el ejercicio de la abogacía por cuenta propia y por cuenta ajena” no son más que opciones para ejercer la profesión, es decir, formas de trabajar según ha establecido la Real Academia Española.

Por tanto, otra vez el Consejo de Ministros (del cual formaban parte las ministras de trabajo y economía), hizo explícito mediante RD la equivalencia entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado como formas de “ejercer la profesión”, es decir, como formas de trabajar (tal cual establece la Real Academia Española).

Diferenciar entre Trabajadores Asalariados y Profesionales Autónomos no deja de ser una mera ficción, que aparece en ciertas regulaciones pero desaparece en otras, y sobre esta ficción precisamente se ha levantado la discriminación cuya eliminación el demandante ha solicitado mediante su Petición a la Ministra.

Por tanto, independientemente de la actual configuración de la estructura ministerial, que no deja de ser una cuestión organizativa y coyuntural, esta parte considera que, como ya indicó en su Solicitud, la Ministra de Trabajo debería ser parte interlocutora en la respuesta a la petición y aportar su reflexión y respuesta a la misma, de manera coordinada con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, incluso si la DGPOLECO sea la entidad que en base al RD 403/2020, Art 5.f, asuma la autoría de la resolución final.

NOVENO.- Se invoca el principio *Iura novit curia* para cuantos preceptos legales y jurisprudencia resulte de aplicación al presente caso.

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA Que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, y tras los trámites procesales pertinentes, tenga por formalizada, en tiempo y forma DEMANDA contra la Resolución Desestimatoria Presunta primero de la Solicitud realizada al amparo del Derecho de Petición (Art 29 CE), y ya en vía judicial, Resolución Desestimatoria Expresa por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previos los trámites legales, y en su virtud se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, se declare la inconstitucionalidad de la situación actual, y se instruya, de acuerdo con el Art 11.2 de la Ley 4/2001, al Ministerio o Ministro competente para que inicie las acciones encaminadas a la realización de la petición, es decir, al establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes para las actividades profesionales, que elimine la actual situación de discriminación.

Y subsidiariamente y para el caso de que la Sala considere que no procede adoptar directamente por la misma las medidas solicitadas, se SUPLICA a la Sala, declare la nulidad de la resolución impugnada; determine, dado el contenido de la Solicitud, cuál es el Ministerio competente para resolver sobre la Petición planteada, si el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digi-

tal, o ambos Ministerios de manera coordinada; y se requiera al Ministerio o Ministro competente para que proporcione una respuesta ajustada a derecho, y en caso de encontrar fundada la pretensión, para que inicie, de acuerdo con el Art 11.2 de la Ley 4/2001, las acciones encaminadas a la realización de la petición.

OTROSÍ PRIMERO DIGO: La ley 37/2011 modifica el apartado 1 del art. 60 de la LRJCA estableciendo que solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.

Y cumpliendo con el mencionado artículo 69.1 LRJCA, se solicita el recibimiento del pleito a prueba que habrá de versar sobre los siguientes puntos litigiosos: legislación y jurisprudencia aplicable, también desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social; estado del sector de la arquitectura en Europa y España; existencia de procedimientos de cálculo de baremos orientativos para honorarios de contratación aprobados por los poderes públicos españoles.

Y a los mencionados fines, esta parte PROPONE los siguientes medios de prueba:

PRIMERO. - DOCUMENTAL: consistente en que se tenga por reproducido el Expediente Administrativo, el presente escrito de demanda, y los documentos que se aportan junto con el presente recurso.

SEGUNDO. - MÁS DOCUMENTAL: Por entender la prueba que se propone trascendente para el cabal conocimiento de la Sala y del propio demandante, se interesa que por esa Sala se requiera al Ministerio de Trabajo y Economía Social para que emita informe -con remisión a los presentes autos- contestando la argumentación del presente escrito de demanda, o cuando menos, de la Solicitud realizada en la vía administrativa.

SUPLICO A LA SALA acuerde de conformidad en el momento procesal correspondiente, admitiendo el medio de prueba propuesto por esta parte.

OTROSÍ SEGUNDO TERCERO DIGO: Solicito, asimismo, para su momento procesal oportuno, y con arreglo a lo establecido en el art. 62 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, que se nos confiera trámite para la formulación de conclusiones escritas.

SUPLICO A LA SALA tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos oportunos.

OTROSÍ TERCERO DIGO: Que, en virtud de los artículos 138 LJCA y 231 LEC, esta parte manifiesta la voluntad de cumplir todos los actos procesales según los requisitos exigidos por la ley, a los efectos de que, caso de haber incurrido en algún defecto formal, la Sala cuide de que pueda ser subsanado.

SUPLICO A LA SALA: Que se tenga en cuenta la anterior manifestación, a los efectos prevenidos en los artículos 138 LJCA y 231 LEC, este último de aplicación supletoria al orden contencioso administrativo.

OTROSÍ CUARTO DIGO que en cumplimiento del art. 42 de la LJCA se fija la cuantía del recurso en indeterminada.

SUPLICO A LA SALA tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos oportunos.

Es Justicia que respetuosamente para principal y otrosíes que se solicita en Madrid a 23 de marzo de 2022.

Fdo.: Letrado

Fdo.: Procurador